

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGOS 318 A 322

Os crimes contra a Administração Pública são os crimes funcionais, praticados pelos funcionários públicos, contra a Administração em geral.

FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO E DESCAMINHO

O art. 318, do Código Penal, trata da facilitação de contrabando e descaminho. Veja a seguir:

CAPÍTULO I DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Facilitação de contrabando ou descaminho

Art. 318. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho (art. 334):

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

O contrabando, que está previsto no art. 334-A, e o descaminho, que está previsto no art. 334, do Código Penal, são crimes praticados por particulares contra a Administração Pública. Já no art. 318, há o funcionário público que facilita, que ajuda na prática desse contrabando ou desse descaminho.

O descaminho é a fraude empregada para iludir a fiscalização alfandegária para não pagar os impostos de importação e exportação. Já o contrabando será o crime de importar ou exportar mercadoria proibida. São condutas distintas, que estão previstas em tipos penais distintos, que serão estudados mais adiante.

O importante é saber que, no art. 318, o tipo penal pune a conduta do funcionário público que facilita o contrabando ou descaminho. Entretanto, em que pese estarmos dentro dos crimes praticados por funcionários públicos contra a Administração em geral, o crime do art. 318 é um crime funcional e, portanto, um crime próprio. Isto é, exige uma qualidade específica do sujeito ativo.

Não é qualquer funcionário público que pode praticar o art. 318. Esse crime só pode ser praticado por aquele funcionário público que tenha a atribuição de fazer a fiscalização alfan-

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

degária. Um funcionário público que não tem qualquer atuação na fiscalização alfandegária não tem como praticar o crime de facilitação de contrabando e descaminho. É disso que trata o trecho “com infração de dever funcional”.

Outro detalhe importante está relacionado ao verbo “facilitar”. Essa facilitação pode ser praticada por meio de uma conduta comissiva ou omissiva. Além disso, com relação a esse crime, há uma hipótese de exceção pluralística. É uma hipótese na qual se aplica a teoria pluralística do concurso de pessoas. Isso acontece porque no Direito Penal brasileiro, o art. 29, do Código Penal, traz a regra da teoria unitária ou da **teoria monista**. Essa teoria afirma que quem concorre para a prática de um determinado crime, responde pela conduta, pelas penas a ele cominadas. Quando há pessoas concorrendo para a prática de um crime, todas elas responderão pelo mesmo delito.

Entretanto, no caso da facilitação do contrabando e do descaminho, há um ou vários particulares praticando contrabando e descaminho e há um funcionário público facilitando, contribuindo para a prática do descaminho. Ainda assim, esse funcionário público não responderá pelo contrabando ou descaminho, mas sim por um crime mais grave (artigo 318). É a chamada **exceção pluralística**.



Características:

1) Crime próprio

É um crime que tem que ser praticado por funcionário público responsável pela fiscalização do contrabando ou descaminho.

2) APPI

É um crime de ação penal pública incondicionada.

3) Crime formal

É um crime formal, que se consuma independentemente da consumação do contrabando e do descaminho. Então, havendo essa facilitação pelo funcionário público, ainda que o contrabando ou o descaminho não venham a se consumir, o crime de facilitação de contrabando ou descaminho estará consumado.

ANOTAÇÕES

4) Competência na Justiça Federal

O contrabando e o descaminho terão competência na Justiça Federal e serão apurados em regra pela Justiça Federal. Logo, a facilitação do contrabando e do descaminho também terá competência na Justiça Federal.

ATENÇÃO

Muita atenção ao art. 318, principalmente quando se trata da exceção pluralística. Na teoria monista, uma vez que particular e funcionário público estão concorrendo para o crime de contrabando e descaminho, o funcionário público responde pela facilitação (art. 318), enquanto os particulares respondem pelo contrabando e descaminho (art. 334-A e 344, a depender da conduta que foi praticada).

Exceção pluralística à teoria monista

Teoria Monista ou Unitária:

CP

Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Funcionário público	Particular
Será responsabilizado pelo crime de facilitação de contrabando ou descaminho (art. 318, CP).	Será responsabilizado pelo crime de descaminho (art. 334, CP) ou contrabando (art. 334-A, CP).

CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA

CAPÍTULO I

DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Condescendência criminosa

Art. 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

ANOTAÇÕES

Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

O verbo “deixar”, neste artigo, não significa que o funcionário esqueceu, foi negligente ou deixou de fazer alguma coisa que deveria ter feito. Na verdade, esse verbo significa que, intencionalmente, de maneira dolosa, o funcionário deixou de responsabilizar o seu subordinado.

Na condescendência criminosa há duas condutas. A primeira é “deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo”. Esse é um delito que só pode ocorrer no âmbito da Administração Pública, não podendo ocorrer no âmbito de pessoas jurídicas privadas. Então, há o superior hierárquico e o seu inferior hierárquico, seu subordinado, que praticou uma infração.

Uma infração pode ser uma falta disciplinar, um crime, uma contravenção, mas, em todos os casos, essa infração tem que ocorrer no exercício do cargo. Logo, se o superior hierárquico tem conhecimento de que seu subordinado praticou um crime como, por exemplo, uma lesão corporal no âmbito de violência doméstica, ele não tem a obrigação de responsabilizá-lo ou de levar a conhecimento de autoridade competente.

Logo, **a condescendência criminosa só pode ocorrer no âmbito de uma infração praticada pelo subordinado, no âmbito da Administração Pública, no exercício do seu cargo**. Se este subordinado pratica um crime, uma contravenção, uma falta disciplinar no exercício do cargo, o superior hierárquico deve promover a sua responsabilização. Entretanto, esse delito pode ocorrer de outra maneira, que é a segunda parte.

A segunda conduta é “quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente”. É a situação na qual há uma pessoa que tem um superior hierárquico, ou uma pessoa da mesma hierarquia que ele. Esse sujeito pode responsabilizar o seu superior hierárquico, ou aquela pessoa de mesma hierarquia? Não. Ele não tem poder para isso e nem competência.

Se por acaso alguém de mesma hierarquia pratica uma infração, obviamente, no exercício do cargo, ele deve levar ao conhecimento da autoridade competente, já que ele não tem competência para responsabilizar. Já se essa pessoa percebe que o seu superior hierárquico praticou uma infração no exercício do cargo, ela também tem que levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, ou seja, alguém hierarquicamente acima do seu chefe, por exemplo.



10m

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

A condescendência criminosa não é um crime que se aplica somente ao superior hierárquico em relação ao subordinado. O superior hierárquico tem que responsabilizar o subordinado, caso este pratique uma infração no exercício do cargo. Entretanto, se alguém de mesma hierarquia ou hierarquia superior pratica uma infração no exercício do cargo, este funcionário público tem que levar o fato ao conhecimento da autoridade competente.

A elementar que vai diferenciar esse crime de outros é o trecho “por indulgência”. A condescendência criminosa só existe quando o funcionário público, seja qual for, deixa de responsabilizar o agente público que praticou uma infração no exercício do cargo **por indulgência**.

A indulgência é a pena, a misericórdia, a compaixão. O superior hierárquico deixa de responsabilizar o seu subordinado porque não quer prejudicar a vida dele.

Já se o superior hierárquico deixa de responsabilizar seu subordinado porque este lhe pagou alguma quantia de dinheiro, por exemplo, não se tem a condescendência criminosa, e sim a corrupção ativa.

Assim, a elementar **indulgência** é indispensável para que ocorra o crime de condescendência criminosa. Se a motivação da não responsabilização for outra, não pode se falar no crime de condescendência criminosa.

Características:

1) Doloso

Esse é um crime doloso. Isto é, um crime que somente pode ser praticado mediante dolo.

2) Crime de menor potencial ofensivo

Tem pena de detenção de quinze dias a um mês, sendo, portanto, um crime de menor potencial ofensivo.



15m

ANOTAÇÕES

3) Crime próprio – crime funcional próprio

Esse crime é funcional próprio, porque, caso se retire a qualidade de funcionário público de sujeito ativo, essa conduta não recairá em qualquer outro tipo penal. Haverá uma atipicidade absoluta dessa conduta caso não for praticada no âmbito da Administração Pública.

Se uma conduta como essa é praticada no âmbito de uma pessoa jurídica, não há crime algum. Pode haver uma responsabilização dentro da empresa, mas não há crime algum. Então, é um crime próprio, que só pode ser praticado por funcionário público, e é um crime funcional próprio, porque, retirada a qualidade de funcionário público do agente, este delito não recai em qualquer outro tipo penal.

4) Crime formal

É um crime que vai se consumir ainda que, posteriormente, aquela pessoa que o agente quis proteger venha a ser responsabilizada.

5) APPI

É um crime de ação penal pública incondicionada.

6) Omissivo próprio

É um crime omissivo próprio ou omissivo puro. Por ser um crime omissivo próprio ou omissivo puro, traz que a conduta é uma omissão, deixar de fazer alguma coisa. Então, se a conduta omissiva é descrita no tipo penal, tem-se um crime omissivo próprio ou omissivo puro.

Por ser um crime omissivo próprio ou omissivo puro, **não admite tentativa**. Os crimes omissivos próprios ou omissivos puros não admitem tentativa, porque a conduta de não fazer algo é uma conduta unisubsistente, são atos de execução que não podem ser fracionados. Então, uma vez que o agente deixa de responsabilizar aquela pessoa que cometeu uma infração no exercício do cargo, já se tem a consumação do crime de condescendência criminosa.

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I

DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

ANOTAÇÕES

Advocacia administrativa

Art. 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:

Pena – detenção, de um a três meses, ou multa.

Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo:

Pena – detenção, de três meses a um ano, além da multa

Patrocinar é advogar, defender, pleitear. Então, é patrocinar, direta ou indiretamente, ou seja, a própria pessoa ou valendo-se de um intermediário, interesse privado perante a Administração Pública, valendo-se da qualidade de funcionário.

Imagine que alguém patrocine um interesse privado perante a Administração Pública. Entretanto, este alguém é um funcionário público e ele está se valendo da sua qualidade de funcionário público para patrocinar este interesse privado. Entretanto, agora, ele está patrocinando um interesse privado legítimo.

Por exemplo, um delegado de polícia tem um conhecido que foi capturado em flagrante delito e levado para outra delegacia. Esse delegado de polícia, diante dessa prisão, tendo a convicção de que seu conhecido não praticou o crime, dirige-se à delegacia na qual esse sujeito foi preso, e conversa com outro delegado. Ele fala para esse outro delegado que não foi seu conhecido que praticou o crime e pede para não lavrar o auto de prisão em flagrante. Isto é, ele está patrocinando diretamente um interesse privado perante a Administração Pública se valendo da qualidade de funcionário público.

Mesmo se esse conhecido de fato é inocente, e o delegado estiver patrocinando um interesse privado legítimo, ainda haverá crime. O art. 321, na sua modalidade simples, no *caput*, punirá a conduta do interesse legítimo que é patrocinado, porque se o interesse for ilegítimo, incidirá a conduta do parágrafo único. Será uma modalidade qualificada do crime de advocacia administrativa.

A pena de detenção de um a três meses ou multa ocorrerá se o interesse privado for legítimo, porque se o interesse for ilegítimo, a pena será de detenção de três meses a um ano, além da multa. A multa, nesse segundo caso, será cumulativa e a pena será maior. Nas duas hipóteses, há crime de menor potencial ofensivo.

Seguindo o mesmo exemplo acima, se o conhecido foi preso e o delegado vai até a delegacia e conversa com o outro delegado, mas sem se valer da qualidade de funcionário



20m

ANOTAÇÕES

público, ele não praticou crime. Ele patrocinou um interesse privado perante a Administração Pública, mas não mencionou que era delegado e não se valeu da qualidade de funcionário público.

A doutrina também afirma que **esse interesse privado deve ser alheio**. Isto, porque, caso o próprio agente defenda interesse próprio, valendo-se da sua qualidade de funcionário público perante a Administração Pública, não haverá o crime da advocacia administrativa.

Características:

1) Menor potencial ofensivo

Seja na modalidade simples, seja na modalidade qualificada, esse delito será de menor potencial ofensivo.

2) Crime formal

Se simplesmente se patrocina o interesse privado, mas não alcança a finalidade que se queria, o crime estará consumado. É um crime formal que independe do resultado naturalístico.

3) Tentativa cabível

A tentativa será cabível quando se tenta patrocinar esse interesse, mas sequer consegue. Por exemplo, uma pessoa tenta falar com um delegado, na outra delegacia para patrocinar esse interesse privado, mas ele sequer fala com a pessoa. Então, ela não consegue advogar pelo interesse alheio por condições alheias à sua vontade.

4) APPI

É um crime de ação penal pública incondicionada.

5) Crime funcional próprio

Caso se retire a qualidade de funcionário público do sujeito ativo, não haverá nenhuma conduta criminosa. Isto, porque é exatamente o trabalho do advogado. Se fosse conduta criminosa, todo advogado seria preso.



25m

VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA

CAPÍTULO I DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Violência arbitrária

Art. 322. Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la:

Pena – detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência.

Obviamente, o sujeito ativo é o funcionário público. Logo, é um crime próprio, um crime funcional. Somente pode ser praticado pelo funcionário público.

Havia uma grande polêmica com relação ao art. 322. A antiga Lei de Abuso de Autoridade, a Lei n. 4.898/1965 trazia tipos penais muito amplos, que até chegavam a desrespeitar o princípio da taxatividade do Direito Penal. Isto, porque eram condutas tão amplas que qualquer forma de abuso de poder, de excesso praticado por um funcionário público, poderia vir a configurar abuso de autoridade.

A nova Lei de Abuso de Autoridade, Lei n. 13.869, de 2019, trouxe tipos penais taxativos específicos e retirou a generalidade que a antiga Lei de Abuso de Autoridade tinha. Então, esse crime do art. 322, do Código Penal, gerava uma polêmica muito grande na doutrina, porque esta entendia que esse artigo havia sido revogado tacitamente pela Lei n. 4.898/1965.

Uma vez que a Lei n. 4.898/1965 foi revogada e a nova Lei de Abuso de Autoridade não traz qualquer tipo penal relacionado a uma suposta violência arbitrária, esse art. 322 volta a ter vida. Com isso, ele passa a ter grande possibilidade incidência em provas de concurso público, porque quase não estava sendo cobrado antes. Esse tipo penal está perfeitamente válido e não há que se falar em revogação desse tipo penal.

Características:

1) Crime funcional = Crime próprio

ANTIGA discussão acerca da revogação do crime previsto no art. 322, CP (Violência Arbitrária)



30m

ANOTAÇÕES

Doutrina	Jurisprudência
Entende que o crime previsto no artigo 322, CP (violência arbitrária) foi tacitamente revogado pelo art. 3º, "I", da Lei n. 4.898/1965 (Abuso de Autoridade), o qual prevê: "Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo".	Tanto o STJ quanto o STF entendem que o tipo penal previsto no artigo 322, CP (violência arbitrária) não foi revogado pela Lei de Abuso de Autoridade. STJ: HC 48083 / MG, julgado em 20/11/2007. STF: RHC 95.617/MG, julgado em 25/11/2008

Esse entendimento do STJ e do STF ganha mais força agora. É o que será adotado. O art. 322, portanto, está perfeitamente válido.

A violência mencionada no artigo tem que ser uma violência física. Uma violência verbal ou moral não configura o delito de violência arbitrária. Essa violência física pode ocorrer por meio de lesão corporal ou pelas vias de fato. Vias de fato são aquelas violências que não deixam lesão corporal como, por exemplo, um tapa na cara. Ainda que não tenha deixado uma lesão corporal, haverá o crime de violência arbitrária.

Além disso, essa violência, como o próprio nome já fala, tem que ser uma violência arbitrária. Uma **violência arbitrária é uma violência injustificada**. Se for uma violência justificada, necessária, praticada pelo funcionário público, ele estará diante de uma legítima defesa própria ou de terceiro, ou diante do estrito cumprimento do dever legal. Portanto, essa violência necessariamente tem que ser arbitrária. Se não o for, não haverá crime algum e será aplicada uma excludente de ilicitude.

Outro detalhe importante é que a pena é de detenção de seis meses a três anos. Logo, este é um crime de médio potencial ofensivo. Ele admite, por exemplo, a suspensão condicional do processo da Lei n. 9.099/1995. Contudo, teremos a imposição de um concurso material obrigatório em relação à pena correspondente à violência.

Por exemplo, a violência gerou uma lesão corporal leve. Nesse caso, tem que impor o delito de violência arbitrária mais a lesão corporal leve. Já se gerou uma lesão corporal grave ou gravíssima, deve-se impor o delito de violência arbitrária mais a pena de lesão corporal grave ou gravíssima. Pode até mesmo ser uma lesão corporal seguida de morte.

Se, por acaso, essa violência arbitrária gerar vias de fato, o agente não responderá pela contravenção vias de fato. As vias de fato restam absorvidas pelo art. 322. Então, quando se tem a pena correspondente à violência, é necessário que a violência, em que se vai impor o concurso material obrigatório, seja uma lesão corporal. Para ficar mais claro, veja o artigo da Lei n. 13.869/2019 a seguir:

ANOTAÇÕES

Lei n. 13.869/2019

Art. 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a:

I – exhibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública;

II – submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei;

III – produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência.

Portanto, se houver uma violência arbitrária com essas finalidades, haverá abuso de autoridade. Entretanto, tratando-se de uma mera violência arbitrária sem que tenha uma dessas finalidades, aplica-se o art. 322 do Código Penal.



35m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
